

1501843-40.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Furlan nº 170, e voltava até o ponto de tráfico. Assim, foi com sua equipe ao indicado ponto de tráfico. Lá encontraram o acusado, o qual possuía as características apontadas pelo denunciante. Ele estava parado no ponto de tráfico e, quando os avistou, agiu de forma suspeita, tentando evitar eventual abordagem. Diante disso, resolveram interpellá-lo e, no bolso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501843-40.2021.8.26.0599 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501843-40.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2327043/2021 - 02º D.P. PIRACICABA, 21716502 - 02º D.P. PIRACICABA, 4754/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2327043 - 02º D.P. PIRACICABA, 2327043/2021 - 02º D.P. PIRACICABA

PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AGNALDO ALVES GALDINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos,

AGNALDO ALVES GALDINO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, c.c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia e seu aditamento (fls. 199), no dia 1º de dezembro de 2021, por volta das 14,24 horas, na rua Algemiro Coelho Ramos nº 236, bairro Água Branca, nesta cidade e comarca, local onde se realizam atividades recreativas e esportivas, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 5 "ependorfs" contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 12,15g; 8 porções de cocaína, na forma de pedras "crack", com peso bruto aproximado de 7,81g e 3 porções de maconha (vegetal contendo THC), com peso bruto aproximado de 10,74g (cf. laudo de constatação de fls. 14/23 e foto de fls. 13), sem autorização

e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que, na mesma ocasião, na rua Nelson Furlan nº 170, nesta cidade e comarca, AGNALDO ALVES GALDINO tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 41 "eppendorfs" contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 49,7g; 44 porções de cocaína, na forma de pedras "crack", com peso bruto aproximado de 12,21g e 63 porções de maconha (vegetal contendo THC), com peso bruto aproximado de 91,16g (cf. laudo de constatação de fls. 14/23 e foto de fls. 13), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narram a denúncia e seu aditamento que guardas municipais foram informados por um transeunte de que um indivíduo alto, trajando bermuda jeans e sem camisa, vendia drogas na rua Algemiro Coelho Ramos, mais precisamente na Praça Antonio Benedito Françoso, local onde se realizam atividades recreativas e esportivas, e se abastecia com entorpecentes no imóvel situado na rua Nelson Furlan nº 170. Os servidores públicos foram ao local e, na rua Algemiro Coelho Ramos, depararam-se com réu, que possuía as características informadas.

Realizada a busca pessoal no suspeito, os GMs localizaram e apreenderam em poder do indiciado 5 "eppendorfs" contendo cocaína, 8 porções de cocaína, na forma de pedras "crack" e 3 porções de maconha, além de R\$ 25,00, provenientes da venda de drogas. Ao ser entrevistado, Agnaldo admitiu que estava traficando.

Dando continuidade à diligência, os servidores públicos foram à casa do acusado e localizaram, dentro do tanque de roupas, mais 41 "eppendorfs" contendo cocaína; 44 porções de cocaína, na forma de pedras "crack", e 63 porções de maconha. Tais porções eram semelhantes àquelas encontradas em poder do réu.

Conclui a denúncia que as circunstâncias da prisão, a quantidade e a variedade de drogas revelaram sua destinação ao tráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 111). Defesa preliminar apresentada às fls. 115/116. Após, a denúncia foi recebida (fls. 117) e o réu foi citado às fls. 142.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Na fase de requerimentos de diligências (fls. 199), o Ministério Público aditou a denúncia para constar que a infração foi praticada na Praça Antonio Benedito Françoso, local onde se realizam atividades recreativas e esportivas, sendo certo que, por ocasião do fato, havia munícipes no local realizando tais atividades, imputando, assim, ao réu, o crime do artigo 33 c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Após manifestação da defesa (fls. 200/202), o aditamento foi recebido (fls. 203/204).

Designada nova audiência, foram ouvidas mais duas testemunhas arroladas pela defesa e o réu foi novamente interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito, bem assim a causa de aumento de pena. Pediu o afastamento do privilégio e a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal.

A Defesa pediu a absolvição por falta de provas e o afastamento da majorante imputada ao réu no aditamento à denúncia, alegando que praça pública não se enquadra no conceito legal. Em caso de condenação pleiteou o reconhecimento do

privilégio e a fixação de pena em regime diverso do fechado.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) Boletim de ocorrência de fls. 07/09;
- 2) Auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e fotografias de fls. 13;
- 3) Laudo de constatação de fls. 14/23 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 100/103, com resultados positivos para tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 05), o réu não quis se manifestar sobre a imputação. Declarou apenas que já havia sido preso por tráfico e por roubo e que, na data dos fatos, não sofreu nenhum tipo de violência, preconceito ou coação para assinar documentos ou confessar.

Interrogado em juízo (gravação), confessou o tráfico, mas não na extensão da denúncia. Disse que em 2017 saiu da prisão e três semanas depois conseguiu um emprego, onde trabalhou até 2019. Depois foi trabalhar com José Ferreira e Sr. Orlando, onde iria ganhar mais, ficando com eles até a data em que foi preso. Alegou que sofreu um acidente em setembro de 2021 e passou a receber auxílio emergencial e outro auxílio do Sr. Orlando. Entretanto, os auxílios cessaram e, na época dos fatos, sua esposa a procurou para pagar pensão da filha que estava passando fome. Como não tinha dinheiro, ficou desesperado e resolveu vender drogas para um traficante. Recebeu dele 30 porções de maconha e 15 de cocaína. No dia dos fatos, escondeu a maconha num buraco na entrada de sua casa. Tinha uma porção de cocaína no bolso para vender (já havia vendido três) e mais R\$ 25,00. Postou-se perto de sua casa para vender os entorpecentes. Não estava na praça. Quando foi abordado pelos guardas, eles encontraram o dinheiro e a porção de cocaína em seu poder. Autorizou-os a ingressarem em sua casa, porque estava confiante de que não iriam encontrar as demais drogas. Eles, entretanto, acabaram encontrando as porções de maconha. Seu pai não estava lá inicialmente e só chegou mais tarde. Não quis fornecer aos guardas o nome do traficante, por medo de ser morto. Por isso, eles lhe intrujaram mais drogas quando o apresentaram na delegacia. Por fim, disse que não conhecia os guardas anteriormente.

No segundo interrogatório judicial, após o aditamento à denúncia (gravação), o réu alterou em parte a versão, mas continuou confessando tráfico. Disse que guardou em sua casa 41 porções de cocaína, 44 de crack e 63 de maconha para um traficante, o qual iria lhe dar R\$ 300,00. No dia dos fatos, saiu para ir a um bar e estava com uma porção de cocaína para seu uso e dinheiro. Os guardas o abordaram e perguntaram se tinha droga em casa. Respondeu-lhes negativamente e os autorizou a ingressarem em sua residência para realizarem uma busca, porque achou que não iriam encontrá-las, mas eles acabaram localizando as drogas.

A confissão do tráfico foi corroborada pelas provas dos autos, mas em maior extensão.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 02) e em juízo (gravação), o guarda civil Francisco Dernival Miranda Junior declarou que fazia parte da equipe da ROMU e, na data dos fatos, estava em patrulhamento pelo Jardim Oriente, quando recebeu informação de um senhor, que não quis se identificar por temer represália de traficantes, de que um homem alto, branco, de bermuda jeans e sem camisa estava traficando no local dos fatos (praça do Jardim Oriente) e que ele, constantemente acessava sua casa, situada a Rua Nelson Furlan nº 170, e voltava até o ponto de tráfico. Assim, foi com sua equipe ao indicado ponto de tráfico. Lá encontraram o acusado, o qual possuía as características apontadas pelo denunciante. Ele estava parado no ponto de tráfico e, quando os avistou, agiu de forma suspeita, tentando evitar eventual abordagem. Diante disso, resolveram interpelá-lo e, no bolso de sua bermuda, encontraram R\$ 25,00 em notas diversas, 05 pinos de cocaína, 08 pedras de "crack" e 03 porções de maconha. Questionado, o réu admitiu que estava realizando tráfico de drogas, alegando que estava desempregado. Admitiu, ainda, morar na casa indicada pelo denunciante, mas negou guardar drogas ali e, confiante de que não encontrariam os entorpecentes, os quais, posteriormente, verificaram estarem bem escondidos em meio a sacos de lixo, franqueou a entrada no imóvel, que ficava a aproximadamente 50 metros de distância do ponto de vendas. Assim, foram até lá e o genitor de Agnaldo, Sr. Geraldo Alves Galdino, que morava nos fundos, também autorizou o ingresso no imóvel e acompanhou a busca lá realizada. Na lavanderia, dentro do tanque de roupas, em meio a sacos de lixo, encontraram uma capa de óculos contendo 41 pinos de cocaína, 44 pedras de "crack" e 63 de porções maconha. Os entorpecentes estavam embalados de forma idêntica aos que foram encontrados no bolso do acusado. As buscas foram realizadas no lado externo da casa e, logo na lavanderia, encontraram os entorpecentes. Seguiram-se as buscas no quarto do réu, onde nada de ilícito foi encontrado. O pai do réu disse que já tinha orientado o filho a parar com a atividade ilícita. Informou, por fim, que o local onde o réu estava postado no momento inicial era conhecido como ponto de tráfico e tratava-se de uma praça onde há área de lazer com brinquedos para crianças e adolescentes, os quais não conseguem brincar sossegados em razão do intenso comércio ilícito de drogas que ocorre na praça. No momento dos fatos, havia famílias usando a área.

No mesmo sentido as declarações prestadas na fase informativa (fls. 04) e em juízo (gravação) pelo guarda civil Felipe Vieira Alves, o qual explicou que a casa do réu ficava na rua Nelson Furlan e que ele traficava na esquina dessa rua com a praça Antônio Benedito Françoso, a qual é comumente frequentada por famílias, pois tem brinquedos para crianças e academias ao ar livre pertencentes à Prefeitura.

Anoto que os relatos dos guardas civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso,

sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos guardas civis: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

As testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram os fatos e, portanto, não

fizeram afirmação contrariando os relatos dos guardas acerca das circunstâncias da prisão do réu.

De fato, Ilda do Vale Cruz, ouvida em juízo (gravação), confirmou que existe uma praça no local dos fatos, onde há parquinho e aparelhos de academia de ginástica. Disse, entretanto, que ela está mal cuidada e que não permite que seu filho a frequente, pois, além disso, é muito mal frequentada, havendo pessoas usando drogas e bebidas ali. Informou que foi feito um “abaixo assinado” pedindo que os brinquedos e academia sejam levados para outro local.

No mesmo sentido as declarações prestadas por Magno dos Santos Pires sob o crivo do contraditório (gravação).

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de mercancia, todas as drogas descritas na denúncia.

De fato, revelaram as provas dos autos que, após receberem informações de tráfico no endereço da denúncia, a qual indicava as características do traficante, bem assim que ele entrava e saía repetidamente de uma casa e retornava até o ponto do tráfico, guardas municipais se deslocaram para lá e encontraram o acusado, o qual tinha as características informadas, no ponto de tráfico. Ele esboçou reação suspeita, como comumente agem os traficantes e, submetido a revista pessoal, foram encontradas diversas porções de diferentes tipos de drogas em seu bolso e dinheiro trocado. Questionado sobre os fatos, ele confessou, informalmente, que estava traficando em razão de estar desempregado e permitiu o ingresso dos agentes em sua casa.

Lá, foram encontradas mais drogas embaladas, as quais eram dos mesmos tipos daquelas que estavam na posse dele (maconha, crack e cocaína) e eram embaladas de forma idênticas.

Tais circunstâncias indicam que os entorpecentes eram destinados ao tráfico, fato, aliás, admitido pelo réu, bem assim que o valor em dinheiro apreendido (R\$ 25,00), em notas trocadas, cuja origem cuja origem lícita não foi comprovada, era produto do crime.

Confirma o destino mercantil das drogas a atitude do réu típica desse tipo de comércio ilegal, qual seja, ficar postado em ponto de tráfico com poucas porções de entorpecentes e dinheiro e, constantemente, acessar o imóvel onde guardava a maior quantidade para se reabastecer.

A variedade e quantidade expressiva de entorpecentes também confirma o destino mercantil.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio

vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

"MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Quanto ao local dos fatos, restou demonstrado que se tratava de área de lazer onde se realizam atividades recreativas e esportivas, a ensejar a aplicação da majorante imputada ao réu no aditamento à denúncia.

Registre-se que o fato de a praça ser mal cuidada ou mal frequentada, como afirmaram as testemunhas arroladas pela Defesa, não impediu que tais atividades de lazer ali se desenvolvessem, fato afirmado pelos guardas.

Por outro lado, em que pesem os argumentos dos nobres Defensores, não prospera a tese de que praça pública com equipamentos de ginástica e parquinho infantil onde são realizadas atividades de lazer e recreação não possa ser considerado local que se enquadre no rol do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

Locais onde há atividades de recreação, independentemente de serem ao ar livre ou fechados, foram considerados pelo legislador como locais em que há maior gravidade da conduta porque existe maior perigo ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública, em razão da reunião de maior número de pessoas.

No caso dos autos, não existem dúvidas acerca da potencialidade da área onde ocorreram os fatos para o agrupamento de pessoas e facilitação da disseminação da droga, sendo inegável que a conduta do réu gerou maior perigo, justificando a aplicação da majorante.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 40, inciso III, da mesma lei.

Passo à individualização das penas.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

A quantidade de drogas, embora mais expressiva, não fugiu à normalidade da espécie a justificar exasperação na primeira fase.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência (condenações definitivas por roubo nos processos criminais de nº 6467-54.2010, fls. 97/98 e nº 16862-42.2009, fls. 98/99, ambos com penas julgadas extintas em 12/05/2017 pela concessão de indulto, fls. 93).

Por outro lado, o réu tem a seu favor a atenuante da confissão da autoria do crime.

Como ambas as circunstâncias são consideradas preponderantes, elas se compensam.

Com fundamento no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento as penas para cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de penas.

Registro que, por expressa disposição legal, a reincidência, que no caso decorre de duas condenações por crimes graves (roubos), impede a aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, presumindo-se a dedicação às atividades criminosas.

A dupla reincidência impõe, por outro lado, a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal (o único compatível com a espécie delitiva e a vida pregressa do acusado), sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis, estes também incabíveis em razão da quantidade de pena aplicada.

Acrescente-se a isso as graves consequências do delito de tráfico, que fomenta a prática de vários outros crimes, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício.

Ademais, a espécie de uma das drogas que o réu traficava ("crack") possui maior poder de viciar o usuário e provocar mais danos em sua saúde.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível a eleição do regime fechado, sem substituição por restritivas de direitos, no crime de tráfico de drogas se a natureza, a reincidência e as circunstâncias concretas do crime indicarem tratar-se de agente de maior periculosidade.

Confira-se recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Revisão criminal – Tráfico de drogas e Trazer arma consigo sem licença – Art. 33, caput, da lei 11.343/06 e art. 19 da Lei de Contravenções penais – Absolvição quanto ao crime de tráfico - Ausência de decisão contrária à prova dos autos –

Robusto conjunto probatório - Narrativas dos policiais militares são seguras, coerentes e indicam o encontro de drogas com o peticionário - Tais depoimentos não devem ser desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa a ele - Ademais, a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos - Em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da culpabilidade do acusado, mas tão somente verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos. E esse não é o caso dos autos, pois a prova colhida no decorrer da instrução resultou suficiente para a prolação de decreto condenatório - Reincidência devidamente demonstrada, o que torna incogitável aplicar o redutor - Regime fechado inalterado, tendo em vista a presença da recidiva do acusado - Pena maior de quatro anos, o que impossibilita a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos - Pedido indeferido." (TJSP - Revisão Criminal 2031611-39.2020.8.26.0000. 4º Grupo de Direito Criminal. Relator (a): Freitas Filho - j. 29/09/2020) - g.n.

Registro que o reconhecimento da reincidência para fins de impedir a concessão de benefícios ao acusado e apená-lo de forma mais grave não fere a coisa julgada, nem constitui "bis in idem", pois não se trata de punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.

Como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, essa ideia "peca pela simplicidade. O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)" (CPComentado - RT, 13ª ed., pag. 464).

Ao se reconhecer a reincidência e aumentar a pena do crime em razão dessa agravante ou deixar de aplicar ao réu alguma benesse, o Estado nada mais faz do que punir com maior rigor o agente que, tonando a delinquir, desafia a ordem pública e as leis vigentes, demonstrando, no dizer do professor Nucci, "persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte, sofre uma punição mais severa" (obra citada, pag. 464).

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico. APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL - Pena fixada com critério e corretamente - Reincidência do réu que inviabiliza a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas - Bis in idem não caracterizado, pois o aumento na segunda etapa e a impossibilidade de aplicação do privilégio na terceira fase são efeitos distintos decorrentes do mesmo instituto - Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por força do disposto nos artigos 44, incisos I e II, e 77, caput, e inciso I, ambos do CP - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso desprovido." (TJSP - Apelação 0003941-43.2015.8.26.0127 - 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Nelson Fonseca Junior - j. 14/09/2017) -g.n.

Pelos mesmos motivos, fica vedado o direito de o réu apelar em liberdade, pois necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Registro que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o tempo de prisão preventiva do réu não é suficiente para progressão de regime.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e seu aditamento, e CONDENO o réu AGNALDO ALVES GALDINO a cumprir cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que a quantia apreendida em poder do acusado, a qual estava junto com as drogas e cuja origem lícita não foi comprovada, é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Conforme acima exposto, o réu é duplamente reincidente em razão de condenações por delitos de roubo, verificando-se periculosidade e real possibilidade de reiteração criminosa. Assim, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual é necessária para garantia da ordem pública e fica mantida.

Recomende-se o réu na prisão em que ele se encontra recolhido, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

P.R.I.C.

Piracicaba, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA